

1500014-05.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Gabriel, sua situação processual não se alteraria caso confessasse o tráfico e também a posse de todos os pinos de cocaína apreendidos, ou caso apenas admitisse o tráfico (levar em conta tratar-se de agente reincidente específico).

Assim é que, a única justificativa para ele ter optado por confessar o tráfico mas não a posse de toda quantidade de cocaína ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500014-05.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500014-05.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2001649/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 22248459 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 85/22/050 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2001649 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 85/22/050 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

KÉLVIN RICARDO ZANINO MARÇAL e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

KELVIN RICARDO ZANINO MARÇAL e GABRIEL MATHEUS SOUZA PEREIRA foram dados como incurso nas penas dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 15h00, no cruzamento entre a Alameda Sócrates com a rua José Gonçalves, 2-18, Jardim Eldorado, nesta cidade, transportavam, traziam consigo e tinham em depósito, 41,47 gramas de cocaína (163 porções) e 40,94 gramas de maconha (182 porções), drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 124 e 126), os réus apresentaram as defesas preliminares de fls. 109/113 e 159/160.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 11 de fevereiro de 2.022 (fls. 178/180).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e os réus foram interrogados (fls. 257 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 269/276).

A defesa técnica do réu Gabriel se manifestou a fls. 281/291, alegando que: 1)- a confissão restou isolada; 2)- as provas são frágeis; 3)- os depoimentos policiais não são suficientes para a condenação; 4)- não restaram comprovados vínculos de estabilidade e permanência que configurassem a associação para o tráfico. Pediu a absolvição e, alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime inicial diverso do fechado com base no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Já a defesa técnica do réu Kelvin se manifestou a fls. 294/300, alegando que: 1)- o crime de associação para o tráfico não se caracterizou; 2)- o acusado faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11343/2006. Pediu a absolvição no tocante ao crime do artigo 35 da Lei n. 11343/2006, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 do mesmo diploma legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão de fls. 31/32 e pelo laudo pericial de fls. 260/265 (sessenta e duas porções de cocaína com peso de 17,17 gramas; cento e uma porções de cocaína com peso de 24,30 gramas; trinta e três porções de maconha com peso de 40,94 gramas; e 149 porções de maconha com peso de 213,99 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos aos acusados.

Em juízo, a testemunha Thiago Luis de Souza, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento nas vias públicas mencionadas no boletim de ocorrência. Visualizou três indivíduos. Ao perceberem a aproximação da polícia, eles fugiram. Gabriel atravessou a via. Já Kelvin e o outro indivíduo adentraram no mato. Notou que Kelvin tinha algo na cintura e, posteriormente, constatou-se tratar-se de uma pochete. Conseguiu abordá-lo. Adentrou no mato, junto com outro policial, atrás de Kelvin, enquanto outros dois policiais da equipe foram abordar Gabriel. O terceiro indivíduo conseguiu fugir. Ao detê-lo, verificou que Kelvin portava uma pochete contendo trinta e três porções de maconha e um aparelho celular. Não viu o que foi encontrado com Gabriel, pois a equipe se subdividiu. Outros dois integrantes da equipe permaneceram para abordar Gabriel, que houvera atravessado a rua. Ao retornar da área de mata, foi informado por seu colega que Gabriel portava sessenta e duas porções de cocaína e quinhentos e quarenta e dois reais em notas diversas e características do tráfico. No mato, cerca de três a cinco metros de distância, foram encontradas mais cento e uma porções de droga. O local em questão foi informado por Gabriel. Não viu a revista realizada em Gabriel. Foi buscar a documentação de Kelvin. Indagado, ele disse que havia mais entorpecentes em sua casa. Na residência, Kelvin apontou que as demais porções estavam em um rack. Tratava-se de cento e trinta e nove porções de maconha. As porções estavam embaladas de forma própria ao comércio. A maconha achada na casa de Kelvin era semelhante àquela localizada anteriormente. Quanto às porções de cocaína, as encontradas na posse de Gabriel e as achadas em meio ao mato eram "exatamente semelhantes". Seu colega lhe mostrou as porções de cocaína posteriormente, quando retornou da área de mata. Os réus assumiram a propriedade do entorpecente e disseram que frequentavam o local há alguns meses para vendê-lo. Kelvin falou que não levava toda a droga para o ponto, que deixava parte em sua casa e que o dinheiro apreendido era produto de vendas anteriores. Eram três horas da tarde e os dois estavam ali desde às três horas da manhã. Quando os avistou, os réus estavam parados. O local é ponto de droga. A mercancia ali não para. Os traficantes se dispersam ao verem a viatura, seja para a rua, seja para a área de mata. O lugar

oferece possibilidades de fuga para os meliantes. Não conhecia os acusados. A testemunha Rodrigo Pereira Barbosa, policial militar, disse que fazia patrulhamento no Parque Roosevelt e avistou um grupo de pessoas. Com a aproximação da viatura policial, os indivíduos se dispersaram. Dois deles fugiram para a mata, um dos quais possuía uma pochete na cintura. Já o terceiro indivíduo se dirigiu a até área habitada do bairro. Seguiu, em conjunto com outro policial, em direção a Gabriel, que tomou rumo da área habitada. Percebeu que ele tinha uma garrafa no bolso. Dentro da garrafa, havia sessenta e duas porções de cocaína e quinhentos e quarenta e dois reais. O sargento Thiago perseguiu os indivíduos que foram para a mata e conseguiu abordar apenas o réu Kelvin. Não presenciou a abordagem de Kelvin mas, depois, foi até o local onde ela se deu. Indagado, Kelvin confessou que havia mais drogas em sua casa. A equipe foi até a residência de Kelvin e ali, em um rack situado na sala, foram localizadas mais cento e quarenta e nove porções de maconha. Gabriel, por sua vez, indicou um local onde acondicionadas mais drogas. No ponto indicado, foram encontradas outras cento e uma porções de cocaína. Todas a cocaína apreendida estava em eppendorfs, cuja cor não se lembra. Indagado, Gabriel confessou a prática do tráfico e explicou que o fazia para sustentar a família, pois passava por necessidade financeira. Ele portava quinhentos e quarenta e dois reais em notas de valores variados e confessou que o dinheiro era proveniente da venda de drogas. Ao vê-los inicialmente, os réus estavam parados. O local é ponto conhecido de tráfico. Toda vez que a viatura adentra no bairro, olheiros avisam os traficantes. O ponto é de difícil acesso. A abordagem também é difícil. Não sabe se, na data do fato, alguém avisou os réus sobre a aproximação da polícia. Não os conhecia. Depois de ter prendido Gabriel, foi até o local onde Kelvin foi abordado. Viu a pochete e trinta e três porções de maconha. Indagou-o e ele confessou que praticava o tráfico. Na casa de Kelvin, ele próprio indicou o local exato onde havia mais droga, a qual estava em um rack.

Interrogado em juízo, o réu Kelvin confessou a prática do tráfico. Passava por necessidades financeiras. Resolveu pegar maconha para vender. Não conhecia Gabriel. Conheceu-o somente quando pegou a maconha para vender. Viu-o pela primeira vez no dia em que foi preso. Disse aos policiais que havia mais drogas em sua casa. Havia comprado o entorpecente, já fracionado, três dias antes da prisão. Tinha trinta e três porções na pochete. Não se lembra quantas porções estavam em casa. Não havia vendido drogas ainda naquele dia.

Interrogado em juízo, o acusado Gabriel confessou a prática do tráfico e admitiu que estava no local. Não tem pais e é sozinho no mundo. Mora na rua. Não tem casa. Praticava o tráfico no local. Estava em cima de uma bicicleta. Conhece Kelvin pois ele é cliente que vai sempre na biqueira comprar droga. A polícia chegou e fez a abordagem. Possuía quinhentos e quarenta e seis reais em dinheiro e quatorze pinos de droga. Viu a polícia e correu. O rapaz que vendia a maconha também correu. Kelvin se assustou e correu. Foi abordado e os policiais apreenderam a droga e o dinheiro. Confessou-lhes que praticava o tráfico, porque tinha duas filhas e era viciado em drogas. Foi jogado para dentro da viatura e conduzido para a margem de residências situadas nas proximidades. Kelvin foi preso no mato e também jogado na viatura. Foram levados até a casa de Kelvin e, dali, para a delegacia. Na delegacia, foram apresentados mais cem pinos de cocaína. Já foi condenado a cumprir cinco anos e dez meses por tráfico. Vendia drogas pois estava devendo para traficantes. Está sem seu dente, porque foi cobrado. Não tem por que assumir o tráfico e não fazer o mesmo em relação à quantidade de droga. Não levou os policiais até o mato. Não tinha sessenta e três pinos de cocaína, mas somente quatorze, bem como quinhentos e quarenta e sete reais em dinheiro. O numerário era proveniente da venda de seis pacotes de cocaína. Tinha sete pacotes. Seu lucro seria de quarenta e cinco reais. Sobraram 14 pinos. Iria sair fora para dar o restante do dinheiro para o dono do movimento. Como somente tinha 14 pinos, não correu ao ver os policiais. Eles jogaram mais drogas e as apresentaram na delegacia. Tem que ser dada credibilidade à sua palavra, porque está assumindo o tráfico. Kelvin está sendo acusado injustamente. Vendia entorpecente para pagar as dívidas. Perdeu o dente porque o "crime" o cobrou na cadeia. Não é envolvido com o "crime". Frequenta a igreja. Quando chegou na prisão, foi difícil explicar para os

"caras" que não estava mais no crime e que a polícia o forjou. Está arrependido do seu ato. Não estava com quantidade elevada de droga. Não levou os policiais para local onde havia mais porções de entorpecente. Acredita que eles lhe atribuíram maior quantidade por pensarem que somente assim iria ser preso.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação dos acusados por crime de tráfico, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em suas defesas que sustentam o contrário.

Os réus confessaram a autoria do tráfico em juízo, livres de qualquer forma de pressão ou coação.

A mera confissão judicial já seria elemento de prova bastante para a condenação, mesmo porque nada indica tenham sido os réus insinceros ao se autoincriminarem. Nesse sentido:

"Prova. Confissão judicial. Único elemento de prova a embasar a condenação.

Admissibilidade. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quanto tiver prova veemente em contrário." (TJSP, RT 744/573).

De qualquer forma, as confissões não estão isoladas no conjunto probatório.

Ao contrário, a prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, que declararam ter flagrado os acusados em ponto de tráfico, na posse de drogas, e Kelvin, na posse também de dinheiro.

As afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Não bastasse, a experiência tem demonstrado que, quando arroladas como testemunhas de tráfico pessoas de fora dos quadros da polícia, elas invariavelmente não dizem a verdade em juízo, pois não querem se expor a delatar publicamente um traficante, possivelmente com medo de eventuais represálias, ou mesmo por terem algum vínculo de intimidade ou amizade com a pessoa processada.

Por outro lado, cabe ainda observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a guarde e a tenha em depósito (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Ao revés, é de rigor a condenação dos réus como incursos nas penas do artigo 33 da Lei Antidrogas.

No tocante ao crime de associação para o tráfico, a absolvição se impõe.

Isto porque não se evidenciou qualquer circunstância capaz de conduzir à crença de existência de um "animus associativo" entre os envolvidos, nem que o vínculo entre

eles era dotado de permanência e estabilidade.

Certo é que, perante os policiais militares, os réus admitiram informalmente que realizavam o tráfico no local há alguns meses.

No entanto, a mera confissão informal, dissociada de outros elementos de prova, não deve se prestar à formação da convicção do magistrado, na medida em que importaria em insegurança para os cidadãos que se veem às voltas com o processo penal.

Confira-se, à propósito, o seguinte julgado:

"Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Confissão informal de Adriana, mencionadas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, que não foi confirmada pelas demais provas. Impossibilidade de condenação exclusivamente com base em elementos de provas colhidos na fase inquisitiva. Art. 155 do CPP. Absolvição mantida." (TJSP, Apelação n. 0000500-40.2017.8.26.0594, rel. Reinaldo Cintra, j. 20 de junho de 2.018).

Do corpo do acórdão, destaca-se:

"Quanto a Adriana, em que pese os policiais responsáveis por seu flagrante tenham dito que ela assumiu a traficância informalmente, fato é que tanto na fase policial como em juízo Adriana negou envolvimento com o tráfico, e o corréu Maykon a isentou de responsabilidade, sendo certo que, conforme bem salientado na r. sentença, a confissão informal, sequer confirmada na delegacia, restou isolada nos autos."

Não se desconhece ainda que, na fase judicial, Kelvin declarou que não conhecia Gabriel, ao passo que este fez afirmação de que conhecia o primeiro como cliente do ponto de tráfico.

Da contradição não deriva, no entanto, a conclusão de que os dois já se conheciam e que praticavam o tráfico no local há meses.

Na verdade, Gabriel não somente contou que conhecia Kelvin como cliente da "biqueira" como também negou que tivesse indicado aos policiais onde estavam as demais porções de cocaína apreendidas com um só fim: o de evitar ser cobrado ou amenizar a cobrança por parte de outros traficantes situados em grau hierárquico superior.

Afinal, estes certamente estavam entendendo que Gabriel poderia ter evitado a perda dos pinos de cocaína que foram achados em meio ao mato por indicação específica sua.

Veja-se que, como deu a entender o próprio Gabriel, sua situação processual não se alteraria caso confessasse o tráfico e também a posse de todos os pinos de cocaína apreendidos, ou caso apenas admitisse o tráfico (levar em conta tratar-se de agente reincidente específico).

Assim é que, a única justificativa para ele ter optado por confessar o tráfico mas não a posse de toda quantidade de cocaína apreendida pode ser encontrada no fato de buscar não ser responsabilizado por seus "superiores" pela perda das porções de cocaína que os policiais apreenderam em meio ao mato.

Tanto tal conclusão é acertada que Gabriel igualmente ressaltou ter tido um dente quebrado na prisão e estar sendo difícil explicar para outros presos que não agia mais no crime.

Enfim, a contradição contida nos interrogatórios dos dois réus (no que toca a já se conhecerem ou não) tem razão de ser outra, que não a de eles buscarem dissimuladamente negar que agiam em comparsaria há razoável período de tempo.

A prova somente permitir afirmar, pois, que se está diante de simples coautoria, sequer sendo possível descartar que a reunião dos acusados para a prática criminosa tenha se dado de forma isolada.

Nessas circunstâncias, não se caracteriza o delito de associação para o tráfico, que exige mais do que a simples coautoria.

Nesse sentido:

"Com relação ao crime de associação (art. 35), em que pese o inconformismo ministerial, tal delito não restou minimamente demonstrado pela prova dos autos, como judiciosamente analisado pela douta Magistrada sentenciante. A conduta descrita no art. 35 da Lei n. 11.343/06 vem representada pelo verbo 'associar', que significa agregar-se, unir-se. Essa associação, no entanto, deve observar um mínimo de estabilidade. Não se confunde, assim, com o mero concurso de agentes. O crime de associação somente se caracteriza quando ocorre estabilidade e permanência entre os

agentes. E sem a prova efetiva de uma verdadeira associação permanente e duradoura voltada à prática do tráfico ilícito de drogas, não há como sustentar um decreto condenatório. Tal qual o crime de quadrilha ou bando, a associação para a traficância exige elo perene e estruturado entre agentes para a prática do crime. O de associação em especial para o crime de tráfico. É delito autônomo e dispensa até a prova do tráfico, suficiente a finalidade da associação. Porém, inadmissível que toda e qualquer comparsaria para a prática delituosa, quando provada, aponte objetivamente a responsabilidade por tal delito autônomo, sendo imprescindível a prova da perene associação entre os sujeitos, com a finalidade específica da traficância." (TJSP, Apelação Criminal n. 0001922-45;2009.8.26.0363, rel. Newton Neves, j. 1º/02/2011).

Logo, a absolvição no tocante ao crime do artigo 35 da Lei Antidrogas é medida de justiça.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu Kelvin não tem antecedentes criminais, razão pela qual sua pena base é estabelecida no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Kelvin não é reincidente (fls. 53), de modo que, na segunda fase de fixação da pena, mantém-se-a no mesmo patamar.

A atenuante da confissão não tem repercussão na redefinição do montante da reprimenda, em face do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Deve ser aplicado o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11343/2006 para Kelvin.

É certo que a apreensão recaiu sobre razoáveis quantidades de maconha (conforme laudo pericial de fls. 260/265: 40,94 gramas + 213,99 gramas) e de cocaína (conforme laudo pericial de fls. 260/265: 17,17 gramas + 24,30 gramas).

No entanto, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, o fato de ser grande a quantidade de droga apreendida, por si só, não significa prova de dedicação à atividade criminosa.

No caso, inexistem outras circunstâncias a apontar que os réus dedicavam-se ao tráfico de forma contumaz.

Sendo assim, pois, é cabível o privilégio.

Porém, levando em conta a considerável quantidade de maconha apreendida, bem como a apreensão de razoável quantidade de cocaína - droga de natureza especialmente prejudicial aos usuários e à sociedade como um todo -, e considerando, ainda, o disposto no artigo 42 da Lei n. 11343/2006, reduz-se a pena na proporção de apenas um quarto, resultando em quatro anos de reclusão, mais quatrocentos dias-multa. Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas para Kelvin.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena para o tráfico, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

Ainda, no julgamento do Habeas Corpus nº 137458/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim dissertou:

"Destaco que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não sendo a paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a hediondez do crime não constitui motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. Fixo, ainda, o regime aberto de início do cumprimento da pena".

Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado para o

tráfico, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se definir o regime no qual o acusado começará a cumprir a sanção.

Considerando as circunstâncias expostas (primariedade, ausência de antecedentes, quantidades razoáveis de drogas e de dinheiro), fixa-se o regime inicial aberto. Levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, e, ainda, o fato de as quantidades de droga e de dinheiro não serem das mais elevadas, entende-se cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo das penas aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Já o réu Gabriel é reincidente (fls. 44 – art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06; fls. 45/46 – art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

No entanto, confessou a prática do crime.

Entende o juízo que a atenuante da confissão, por dizer respeito à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

"Por envolver a personalidade dos agentes, a atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante e deve ser compensada com a agravante da reincidência."

(HC n. 288.910/SP, 6ª Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. Em 21/10/2014) (em TJSP, Apelação n. 0020654-38.2013.8.26.0071, j. 21/05/2015).

No caso concreto, no entanto, não se pode determinar pura e simplesmente a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante, pois, como visto, são duas as condenações anteriores hábeis a ensejar a reincidência.

Nessa ótica, o melhor a fazer é desconsiderar apenas parcialmente o efeito das condenações pretéritas.

Nesse sentido:

"... não há como se operar a compensação integral ante a constatação de múltiplas reincidências. A melhor solução para a hipótese, a fim de não desprestigiar a confissão proporcionada pelos réus, é desconsiderar uma das condenações que caracterizam a reincidência e acrescer à pena patamar de aumento somente pelas condenações restantes." (TJSP, Apelação n. 0023777-06.2010.8.26.0344, rel. Salles Abreu, j. 28/02/2012).

Sendo assim, na segunda fase de aplicação da pena, considerando a reincidência e sua parcial compensação com a atenuante da confissão, eleva-se a pena na proporção de apenas um sexto, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas para Gabriel.

Ante o montante da pena aplicada e a reincidência específica, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado para Gabriel.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para: 1) condenar o réu Gabriel Matheus Souza Pereira como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11343/2006, a cumprir cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos e oitenta e três dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo e, para absolvê-lo do cometimento do delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e; 2)- condenar o réu Kelvin Ricardo Zanino Marçal como incurso nas penas do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, a cumprir quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar 400 dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução e, para absolvê-lo do cometimento do delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Oportunamente, anotem-se as condenações no sistema informatizado.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao celular apreendido, é bem cuja posse, por si só, não configura fato ilícito. Dessa forma, aguarde-se por noventa dias a contar do trânsito em julgado eventual pedido de restituição. Na inércia, os bens deverão ser doados ou inutilizados, nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP.

O réu Gabriel foi preso em flagrante e permaneceu custodiado durante a instrução. Agora, condenado a cumprir pena longa, em regime inicial fechado, com maior dose de razão deve permanecer encarcerado provisoriamente, pois há o risco de que, se solto, busque se subtrair da aplicação da lei penal, sem contar a probabilidade de reiteração da mesma prática criminosa, tendo em vista os antecedentes. Expeça-se, pois, ofício de recomendação.

P.R.I.

Bauru, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA